

RECURSO CÍVEL Nº 5086483-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LÍCIA FERNANDA DA ROCHA LOPES (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, CF/88. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE ATRASADOS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ. PRECEDENTES DO STJ. EDCL NO RESP 1192556/PE - REPETITIVO E RESP 1607418/RS. PARCELA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA QUE INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS. ARTIGOS 41, 63 E 76 DA LEI Nº 8.112/90. EVENTUAIS DIFERENÇAS DEVEM SER APURADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO COM REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS, SENDO POSSÍVEL INCLUSIVE A COMPROVAÇÃO CONTÁBIL NESSE MOMENTO, DE QUE A VERBA JÁ COMPÕE A BASE DE CÁLCULO CONCRETO EM RELAÇÃO AO ACRÉSCIMO DE FÉRIAS OU À GRATIFICAÇÃO NATALINA, QUANDO ENTÃO NÃO HAVERÁ O QUE EXECUTAR FRENTE A ESSA VERBA. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Condenação da recorrente em honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5086483-36.2024.4.02.5101

510015469408 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5086483-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: LÍCIA FERNANDA DA ROCHA LOPES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela União, em face da sentença de procedência do pedido para inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

Segue a sentença:

*Trata-se de ação proposta por **Lícia Fernanda da Rocha Lopes** contra a **União**, objetivando, em síntese, a inclusão do valor pago a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias, bem como o pagamento das diferenças daí decorrentes.*

Breve relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, não há falar-se em sobrestamento do feito, porque não existe determinação de suspensão nacional.

O Tema 346 da TNU discute "se a percepção da rubrica 'abono de permanência EC 41/03 gratificação natalina' configura duplicidade, em relação à pretensão de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina". Inexiste, todavia, ordem de suspensão dos processos correlatos.

Quanto ao Tema 1.233 em recursos repetitivos, no qual o STJ definirá "se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) dos servidores públicos federais", a ordem de sobrestamento se restringe aos REspS e AREspS em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça. Não é o caso dos autos.

Das preliminares

Afasto a impugnação ao valor da causa, eis que a ré sequer indica o valor que entende ser o correto.

A petição inicial está instruída com a documentação suficiente ao julgamento do feito, inclusive com o termo de renúncia ao que superar o limite de alçada deste juízo.

Da prescrição

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 alcança somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação e não atinge o fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.

O adicional de férias incide sobre a remuneração do servidor público federal, conforme prevê o art. 76 da Lei nº 8.112/90, in verbis:

Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional **correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias**.

A seu turno, a gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor faz jus na competência de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano (art. 63, Lei nº 8.112/90).

De acordo com o art. 41 do mesmo diploma legal, a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Como se observa, a literalidade dos preceptivos legais destacados é clara ao determinar que a base de cálculo, tanto do terço de férias como do 13º salário, tem como referência a remuneração do servidor.

Neste contexto, faz-se mister analisar a natureza jurídica do abono. O direito ao abono de permanência foi incluído na CRFB/88 pela EC n. 41/2003 como um benefício devido aos servidores que completassem os requisitos necessários à concessão da aposentadoria voluntária e optassem por permanecer na atividade.

O objetivo do legislador constituinte, ao criar o abono de permanência, foi o de oferecer uma compensação ao servidor que implementasse os requisitos para a aposentadoria voluntária, em valor correspondente ao de sua contribuição previdenciária, a fim de estimular a sua permanência no serviço público, evitando o gasto com novas contratações.

Não se trata, portanto, de parcela eventual, provisória, de caráter indenizatório, mas de vantagem remuneratória permanente, que se enquadra no art. 41 da Lei nº 8.112/90, destinada a incentivar a continuidade do servidor na ativa.

Note-se que o fato de não incidir contribuição previdenciária sobre o abono não modifica sua natureza jurídica, que continua sendo de parcela remuneratória e permanente. A não incidência tributária, no ponto, foi mera opção legislativa, que excluiu a rubrica da base de cálculo da exação em tela.

Não bastasse isso, impende frisar que os valores recebidos pelo servidor sob a forma de abono de permanência estão inseridos no campo de incidência do imposto de renda, conforme tese firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 424, tendo como representativo da controvérsia o REsp nº 1192556/PE, em que se conclui que tal verba, indubitavelmente, importa acréscimo patrimonial.

Deveras, a jurisprudência do STJ, sobretudo no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1192556/PE, pacificou o entendimento de que o abono de permanência é de natureza remuneratória, por acrescer ao patrimônio e configurar fato gerador do imposto de renda, independentemente de não incidir contribuição previdenciária, de modo que é justificável que tal verba componha a base de cálculo do terço de férias e do 13º salário.

Assim, fixada a premissa de que o abono possui caráter remuneratório, ele deve integrar, para todos os efeitos, a base impositiva do adicional de férias e da gratificação natalina.

Confirmam-se, na mesma linha de raciocínio, os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INTEGRAÇÃO DEVIDA. 1. De acordo com o inciso XVII do artigo 7.º da Constituição Federal e o artigo 76 da Lei n.º 8.112/1993, o cálculo do adicional de férias é feito com base na remuneração regularmente recebida pelo servidor público que, nos termos do caput do

artigo 41 da Lei n.º 8.112/1990, é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 2. O abono de permanência é rubrica paga ao servidor público que, tendo implementado os requisitos necessários à aposentadoria, opta por permanecer em atividade, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. A natureza jurídica do abono de permanência foi objeto de longa controvérsia na jurisprudência pátria, vindo a ser finalmente pacificada, no sentido da natureza remuneratória. Precedentes do STJ. 4. O fato de sobre o abono de permanência não incidir contribuição previdenciária não influencia sua natureza jurídica, que permanece sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente. 5. **Face à natureza remuneratória da parcela relativa ao abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base para o cálculo do terço constitucional de férias.** (TRF4 5062655-86.2015.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 18/07/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 1. Nos termos do disposto no artigo 76 da Lei nº 8.112/90, em consonância com o artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, o adicional de férias é calculado com base na remuneração do servidor, isto é, no vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 2. Acerca da **natureza jurídica do abono de permanência, tem-se que é verba remuneratória de caráter permanente, pois é devida aos servidores que implementam os requisitos à aposentadoria voluntária, mas optam por permanecer em atividade, desde a data em que poderiam se aposentar até quando, de fato, ingressem na inatividade.** 3. **A natureza jurídica do abono de permanência foi objeto de longa controvérsia na jurisprudência pátria, vindo a ser finalmente pacificada, no sentido da natureza remuneratória.** Precedentes do STJ. (EDcl no REsp 1192556/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 17/11/2010). 4. **Assim, face à natureza remuneratória da parcela relativa ao abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base para o cálculo do terço constitucional de férias.** 5. Difere-se para a fase de cumprimento da sentença a forma de cálculo dos consectários legais submetida ao que vier a ser decidido definitivamente pelo STF no julgamento dos embargos RE 870.947/SE, julgando prejudicado o recurso da parte ré quanto à aplicação da Lei nº 11.960/2009. 6. Negado provimento ao recurso inominado da parte ré. (TRF4 5006834-86.2018.4.04.7102, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora JOANE UNFER CALDERARO, julgado em 16/04/2019)

Por fim, cumpre destacar que a rubrica "ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT.NAT." representa tão somente a devolução a título de abono de permanência do mesmo valor que foi recolhido sob a denominação "CONTR.PSS - GRATIF. NATALINA", que corresponde à contribuição previdenciária que incidiu sobre o montante do décimo terceiro percebido pelo servidor.

Não merece prosperar, portanto, a argumentação ventilada na peça de defesa, de modo que o acolhimento do pleito é a medida que se impõe.

III - DIPOSITIVO

Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** para condenar a ré a **incluir** o valor pago a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, observadas as diretrizes elencadas nos arts. 63 e 76, da Lei nº 8.112/90, e a **pagar** as diferenças daí decorrentes, que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data em que cada parcela era devida, e acrescidas de juros de mora, a contar da citação, com base nos índices e taxas previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, observando-se a prescrição quinquenal, inclusive com a incidência, em uma única vez, da SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021.

Recurso inominado no evento 19. Alega a União a necessidade de sobrestamento do processo até a apreciação dos Temas 346 e 1233, respectivamente, da TNU e do STJ. No mérito, sustenta que o abono de permanência não se confunde com verba remuneratória, uma vez que não se trata de vantagem pecuniária permanente.

VOTO

De início, destaco que esta relatora tem ciência da decisão de afetação constante no âmbito do ARES nº 2033159/RS, do ARES nº 2.031.906/RS e do REsp nº 1.984.872/CE à sistemática de recurso especial repetitivo pelo STJ. Todavia, não houve determinação de suspensão de julgamento de lides da espécie em instâncias ordinárias.

Especificamente quanto ao **Tema Repetitivo nº 1.233 do STJ**, vê-se que a determinação de suspensão se restringe aos Resps e AREsps em segundo grau de jurisdição e/ou na própria Corte Superior, não se estendendo ao caso dos autos. Confirma-se:

Tema Repetitivo 1233	Situação Afetado	Órgão julgador	PRIMEIRA SEÇÃO	Ramo do direito	DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Definir se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) dos servidores públicos federais.				
Anotações NUGEPNAC	Dados parcialmente recuperados via sistema Athos - PGU - AGU. Afetação na sessão eletrônica iniciada em 6/12/2024 e finalizada em 12/12/2023 (Primeira Seção). Vide Controvérsia n. 422/STJ.				
Informações Complementares	Há determinação de suspensão dos REspS e AREspS em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça, adotando-se, neste último caso, a providência prevista no art. 256-L do RISTJ.				

Quanto à prescrição quinquenal, esta já restou devidamente reconhecida pelo juízo *a quo*.

A questão a ser reapreciada diz respeito à natureza jurídica da verba abono de permanência, que se for remuneratória e permanente deverá integrar a base de cálculo do décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, nos termos pedidos pelo recorrido.

Sobre o abono de permanência dispõe a Constituição Federal:

"Art. 40. (...)

(...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)."

Por seu turno, a Lei nº 8.112/90 fala em seu artigo 41 sobre a remuneração do servidor:

"Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei." (grifei)

Quanto à natureza jurídica da verba abono de permanência, se indenizatória ou remuneratória, o STJ consolidou seu entendimento quando do julgamento de embargos de declaração em recurso especial julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 424) e decidiu que é verba de natureza remuneratória. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Por inexistir fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter o acórdão do Tribunal de origem quanto à questão impugnada no recurso especial, não há falar em incidência da Súmula 126/STJ.

2. Esta Seção manifestou-se sobre a natureza jurídica do abono de permanência, quando prestigiou, no acórdão embargado, o entendimento da Segunda Turma, que, ao julgar o REsp 1.105.814/SC, sob a relatoria do Ministro Humberto Martins, reconheceu a incidência do imposto de renda sobre o aludido abono com base nas seguintes razões de decidir: "O abono de permanência trata-se apenas de incentivo à escolha pela continuidade no trabalho em lugar do ócio remunerado.

*Com efeito, é facultado ao servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para a aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio. **O abono de permanência possui, pois, natureza remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.**" (grifou-se). Com efeito, o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito.*

3. Verificar se o acórdão embargado enseja contrariedade a normas e princípios positivados na Constituição é matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal, alheia ao plano de competência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que para fins de prequestionamento, conforme entendimento da Corte Especial (EDcl nos EDcl nos EREsp 579.833/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 22.10.2007).

4. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp 1192556/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 17/11/2010)

Em sequência, o STJ também tem forte jurisprudência sobre ser o abono de permanência verba permanente, afastando o caráter transitória, posto que somente se extinguirá com a aposentadoria do beneficiário, Confira-se:

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. A orientação da Corte Especial do STJ é no sentido de que, em Execução contra a Fazenda Pública, é possível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, ou seja, em relação ao montante do valor executado que não foi objeto de Embargos à Execução.

3. Cumpre registrar que, no âmbito federal, a orientação do STJ foi consolidada na Súmula 31/AGU, in verbis: "É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública."

4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ele cessará. (grifei).

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório.

6. O mesmo se diga em relação ao auxílio-alimentação, porquanto o Superior Tribunal de Justiça entende que tal verba, quando paga em dinheiro, possui natureza remuneratória.

7. Recurso Especial desprovido.

(REsp 1607418/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016)

Ressalte-se que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão sobre a natureza do abono de permanência é de âmbito infraconstitucional (ARE 1273308 / RS - Relator(a): Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 27/08/2020; RE 758345 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, DJe em 17/04/2018).

Assim, conjugando-se as normas legais e o entendimento do STJ sobre o tema, entendo correta a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e considerou o abono de permanência de natureza remuneratória e permanente que deve integrar a base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, nos termos dos artigos 63 e 76, ambos da Lei nº 8.112/90.

Nada obstante, trago importante observação procedida por esta Turma, no que tange ao cumprimento de sentença para a hipótese vertente, nos autos do processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117, de Relatoria da Dra. Daniella Motta, julgado na sessão virtual de 08/11/2022. Segue trecho do voto:

"Ocorre que, recentemente, em razão de questionamentos em sede de cumprimento, em lides análogas, apurou a contadoria judicial que a base de cálculo da gratificação natalina, conforme os protocolos de cálculos, já inclui o valor do abono de permanência

Ao passo que para cálculo do terço de férias, o abono de permanência não integra sua base de cálculo.

Destaco que, ao que se observa das fichas financeiras dos servidores, o abono de permanência é pago em rubrica própria, como crédito autônomo, compensando o débito de PSS.

Remetido aos autos à Contadoria Judicial constatou-se que ao menos para os servidores do Poder Executivo Federal já há inclusão do abono de permanência na base de cálculo da Gratificação Natalina, o mesmo não ocorrendo com relação ao terço de férias.

De forma que, para a gratificação natalina não há, a priori, lide. Contudo, considerando que não se sabe desde quando essa forma de cálculo foi adotada, bem como se para os demais poderes a sistemática é a mesma, entendo que o mais adequado é reconhecer o direito, devendo as eventuais diferenças serem apuradas em sede de cumprimento com realização de cálculos concretos, sendo possível a apuração de cálculo zero no tocante a Gratificação Natalina.

Nesse sentido, cito os cálculos efetuados no processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117/RJ, considerando as fichas financeiras constantes dos autos como paradigmas (evento 59 - inf 1 e evento 1, finanac8). Outrossim, como o abono de permanência é uma verba estipendial permanente remuneratória, paga como verba própria a crédito no valor do PSS deve fazer parte da base de cálculo tanto da gratificação natalina, como já faz, assim como do terço de férias.

Por fim, destaco que o legislador constitucional poderia ter determinado a imunidade de PSS como forma de incentivo a manutenção da atividade. Contudo, não o fez desta forma, mas sim com pagamento de verba permanente no valor máximo correspondente a contribuição. Por conseguinte, não vislumbro razão para incluir o abono na base de cálculo

da gratificação natalina e não no terço de férias. O fato de haver isenção legal quanto ao adicional de férias no tocante ao PSS não altera sua base de cálculo (parágrafo primeiro do art. 4 da Lei 10.887/2004)."

Desse modo, o pleito é procedente, mas deve ser permitido que, em sede de execução, caso se verifique contabilmente que o acréscimo de férias ou a gratificação natalina aqui reclamadas já são pagas pela Administração com o abono de permanência na composição da sua base de cálculo, não haverá o que se executar em relação às diferenças em questão.

Isto posto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Condenação da recorrente em honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

5086483-36.2024.4.02.5101

510015469407 .V4